

1500647-64.2022.8.26.0481

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500647-64.2022.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500647-64.2022.8.26.0481 - Feito nº 2022/001887

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2202525/2022, ofereceu denúncia em face de JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ALMEIDA, devidamente qualificado às fls. 24, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 26/07/2022, por volta das 17 h, na Rua Recife, 1679, Praça da Bíblia, Vila Cruzeiro do Sul, nessa cidade e Comarca, JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ALMEIDA estaria trazendo consigo, para entrega a consumo de terceiros, duas porções de maconha, pesando 05 gramas, e 10 porções de crack, pesando 0,9 grama; bem como estaria mantendo em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 18 porções de maconha, pesando 41 gramas, drogas capazes de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

Realizada audiência de custódia virtual, após a entrevista do autuado e manifestação do ilustre representante do Ministério Público e da nobre Defesa, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva na data de 27/07/2022 (fls. 59-67).

Notificado (fls. 96), o acusado ofertou defesa prévia (fls. 106-109).

A denúncia foi recebida em 24/08/2022, ocasião em que foi rejeitada a hipótese de absolvição sumária, com fundamento no artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, que autorizou a realização das audiências por

videoconferência ou mistas em todas as matérias, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 116-119).

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (fls. 141-143 e 144-146).

O réu foi regularmente citado (fls. 156).

Prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico para o descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, ainda, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ALMEIDA pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 06-07), boletim de ocorrência (fls. 13-15), auto de exibição e apreensão (fls. 17 e 19), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 18) e laudos periciais químicos de entorpecente (fls. 141-143 e 144-146), que atestaram que as substâncias se tratavam de cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), que são de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ALMEIDA.

Inquirida, a testemunha DANIEL APARECIDO DE JESUS, policial militar, relatou que "No dia dos fatos, estávamos em patrulhamento próximo à praça da Bíblia, local conhecido na cidade pelo uso e pela venda de drogas. Visualizamos João Victor na via pública. Ao avistar a viatura, a uma distância de aproximadamente 20 metros de onde estávamos, o rapaz jogou algo ao solo e mudou a direção em que vinha pela via pública. De imediato, realizada a abordagem: em busca pessoal, estava em seu poder um aparelho celular. Em varredura pelas imediações, no mesmo local onde ele havia dispensado algo, encontramos em um invólucro contendo dez pedras de crack e duas porções de maconha. Diante dos fatos, apresentamos o caso à Delegacia de Polícia. O delegado pediu que fôssemos até a casa dele comunicar sua mãe sobre a prisão, o que fizemos. Em contato com ela, pedimos que nos autorizasse vistoriar o quarto do rapaz. Ela nos autorizou por escrito e, em busca domiciliar no quarto do réu, dentro de um tênis havia uma sacola plástica dezoito porções de maconha idênticas àquelas que foram encontradas com ele na via pública. Salvo engano, por volta das 17h. Havia uma pessoa caminhando longe dele: era um menor de idade, que também foi abordado. Os dois, no local, diziam não estar um em companhia do outro. Informalmente, ele disse que, realmente, trazia essa droga para a venda. Não havia dinheiro com ele, nem em sua casa. Na residência dele foi localizada somente a maconha, nenhum petrecho típico de mercancia. Também não (nenhum petrecho típico de usuário)".

No mesmo sentido, o também policial militar ALCIONE ALVES CARDOSO, o qual complementou "Sim, Excelência. No dia dos fatos, estávamos realizando policiamento por Presidente Epitácio, nas proximidades da praça da Bíblia, local comum de tráfico de drogas. Nos deparamos com João Vítor ali nas proximidades. Conforme nos aproximávamos com a viatura, ele dispensou alguns objetos que trazia consigo ao solo e, rapidamente, mudou a direção em que caminhava pela via pública. Realizada a abordagem nele, identificamos que ele tinha jogado ao chão três invólucros: dois de maconha e o outro com dez porções de crack. Ele assumiu a propriedade da droga, que seria vendida naquela região. Em seguida, ao irmos até sua casa cientificar sua mãe sobre o caso, ele é conhecido dos meios policiais, a mãe desabafou conosco, permitiu nossa entrada e, em vistoria na residência, em seu quarto, dentro de um tênis da marca Mizuno encontramos 18 porções de maconha. O caso foi apresentado à

delegacia de polícia. Foi por volta das 17h. Olha, tinha outro rapaz que estava, assim, um pouco atrás dele. Ele foi abordado, mas declarou não ter nada a ver com a ocorrência e o João Vítor assumiu a propriedade da droga, por isso o liberamos. Mas eles não estavam juntos: João Vítor estava adiante e o outro um pouco mais atrás". Interrogado, o acusado JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ALMEIDA negou a prática delitiva, dizendo que "Eu quero falar, senhora. Era para eu usar. Eu fumo crack. É, e maconha. Sou usuário. Porque eu tinha acabado de comprar. Paguei R\$ 200,00. Trabalho, senhora: sou servente. Para eu não ficar precisando ir à biqueira, senhora. Tinha, senhora. Para eu fumar, senhora. Sim, senhora. Não, senhora". Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado se encontra em dissonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas policiais militares que empreenderam as investigações e efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livra-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irrealidade.

Nada indica que os policiais tenham criado uma situação para acusar falsamente o acusado.

As testemunhas de acusação descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos, de forma que, tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos.

A presunção iuris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Outrossim, o fato de o acusado ser usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do delito de traficância.

Pelo contrário, não é raro que usuários passem também a comercializar entorpecentes justamente para garantir o próprio vício, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra.

Nessa toada:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJSP 101/498).

"Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio" (RT 710/325).

Cabe ressaltar que a variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento, em porções individuais, prontas para a mercancia, além da ausência de petrechos comumente utilizados por usuários de drogas, são totalmente incondizentes com a alegação de porte para consumo pessoal.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a variedade de entorpecentes apreendidas em poder do acusado (crack e maconha); a relevante quantidade de entorpecentes (46 gramas de maconha e 0,9 grama de crack); o modo de acondicionamento (20 invólucros plásticos de maconha e 10 pedras de crack, todos embalados individualmente e prontos para o comércio - fotografias de fls. 36-37); o local onde se deram os fatos (denúncias anônimas davam conta de que o acusado venderia drogas nas proximidades da Praça da Bíblia, local em que foi abordado); a tentativa de ocultação do entorpecente (o acusado dispensou duas porções de maconha e dez porções de crack que trazia consigo assim que visualizou a viatura policial); a confissão informal do réu aos policiais que o prenderam; as diferentes versões apresentadas pelo acusado em solo policial e em juízo; as circunstâncias da apreensão das drogas (18 porções de maconha foram localizadas dentro do guarda-roupas, no quarto de João Victor) e a alegação quicá fantasiosa de que havia adquirido considerável quantidade de crack e maconha "para não ficar indo na biqueira", uma vez que já possuía 18 porções de maconha em sua residência, revelam que não se tratava de simples porte para consumo pessoal, mas sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros.

E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis. Isso porque deixo de considerar, nesta fase de dosimetria, a fim de evitar "bis in idem", os critérios constantes do artigo 42, da Lei de 11.343/06, uma vez que tais circunstâncias serão consideradas na terceira fase de dosimetria.

Nesse sentido:

"[...] a Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, ainda, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza, o bis in idem. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder de discricionariedade, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem" (STF - HC: 121853 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: Dje-213 DIVULG 29-10-2014).

Destarte, considerando que não ostenta o réu maus antecedentes criminais e que

todos os demais elementos são inerentes ao tipo penal, fixo as penas no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, vislumbro a circunstância atenuante da menoridade relativa, vez que o acusado possuía, à época dos fatos, 19 anos de idade (fls. 24). No entanto, mantenho as penas anteriormente fixadas, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de cálculo penal, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa. No entanto, verifico que o acusado foi flagrado trazendo consigo e guardando substância altamente letal ao ser humano, qual seja, crack, o que impõe a redução no patamar mínimo de 1/3, totalizando 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

“Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida.” (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, excepcionalmente, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade, conduta social, personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser corrigida monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR JOÃO VITOR NASCIMENTO DE ALMEIDA, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 333 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade; e prestação pecuniária em favor de instituição pública ou privada de destinação social no montante de um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Considerando o regime inicial fixado e que o acusado e que não mais estão configurados os requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado (ausência de

periculosidade atual, encerramento da fase de instrução, residência fixa e primariedade), concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se, desde logo, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro não estiver preso.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Concedo ao sentenciado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente remanescente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) sentenciado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

de Presidente Eptácio, 06 de outubro de 2022

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.